

1502598-41.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Jardim das Flores, cep 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo Digital 1502598-41.2021.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502598-41.2021.8.26.0542

Controle: 2021/001870

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

MARCOS PEREIRA DA SILVA, JHEIMESON BALZAN e ROGÉRIO AUGUSTO RATTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

ROGÉRIO AUGUSTO RATTI, JHEIMESON BALZAN e MARCOS PEREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados por incursos nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos c.c. o artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, em 7 de novembro de 2021, por volta das 6h50, na Praça Filinto Müller, 86, Santo Antônio, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, associados entre si, transportavam e traziam consigo: 135 tabletes, contendo 94,1kg de maconha, substância entorpecente, capaz de determinar a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, nas mesmas circunstâncias tempo-espaciais, associaram-se entre si para a prática do tráfico de drogas.

Apurou-se que Rogério Augusto, Jheimeson e Marcos, residentes em Cascavel-PR, compunham entre si e com outras pessoas, não-identificadas, associação criminosa para o tráfico ilícito de drogas.

Assim, Marcos, por meio de Hugo Jeferson Peterson, vulgo Huggg Bb, recebia a droga e efetuava seu transporte do Paraná para São Paulo.

Para tanto, Marcos contava com a ajuda de Rogério Augusto e Jheimeson, sendo que um deles exercia também a função de batedor, seguindo na frente para constatar eventual existência de ação policial, enquanto o outro era responsável por transportar a droga.

Com efeito, no dia dos fatos, todos saíram da cidade de Cascavel-PR com o

carregamento de drogas e rumaram para Osasco-SP.

Nesse sentido, Marcos, na condução do automotor Hyundai HB20, QIV-5E33, e Jheimeson, na condução do veículo FIAT Argo, RNW-3E83, partiram primeiro, a fim de assegurar o caminho de Rogério, que transportava o entorpecente no automóvel FIAT Siena, IWK-3A49.

Eles entravam em contato entre si a todo momento, notificando circunstâncias relevantes para o transporte seguro da droga, compartilhando entre eles suas localizações em tempo real.

Ocorre que aportou informação na D.I.S.E.-Osasco de que haveria uma encomenda de drogas a ser realizada no endereço do ocorrido, dando conta, inclusive, dos veículos responsáveis pelo transporte do entorpecente.

Assim sendo, policiais civis para lá se dirigiram, com vistas ao atendimento da notícia, onde, após breve campana, visualizaram Marcos e Rogério Augusto chegando ao local e ali estacionando.

Como conduziam os veículos informados na notícia, tendo os agentes policiais puderam observar que o automotor conduzido por Marcos - Hyundai HB20 - parecia escoltar o veículo conduzido por Rogério Augusto - FIAT Siena - eles decidiram efetuar a abordagem.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ambos. No entanto, no assoalho, por baixo dos bancos, e porta-malas do veículo FIAT Siena, conduzido por Rogério Augusto, os policiais civis encontraram o entorpecente.

Indagados, ambos, prontamente, confirmaram a prática delitiva, acrescentando, ainda, a participação de Jheimeson, indicando que ele se encontrava parado junto a um posto de combustíveis na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, aguardando que chegassem.

Ato contínuo, os agentes policiais rumaram para o local informado e detiveram Jheimeson ali parado, embarcado no automotor FIAT Argo. Abordado, Jheimeson também confessou sua participação, confirmando ser o batedor.

Diligências foram encetadas, após a apreensão de Rogério Augusto, Marcos e Jheimeson, tendo sido deferida quebra de sigilo dos dados dos aparelhos telefones celulares deles, onde se confirmou a associação criminosa, sendo que Marcos entrava em contato com Hugo, o qual lhe entregava o entorpecente, bem como as instruções acerca dos valores de venda e, que, após, Marcos entrava em contato com Rogério Augusto e, este, por sua vez, com Jheimeson.

A denúncia foi oferecida, sendo regularmente notificados Marcos, Rogério Augusto e Jheimeson (fls. 325/327). Sobrevieram as defesas preliminares (fls. 319/321, 331/336 e 339/354) e, não havendo causas para a sumária absolvição, a denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2022 (fls. 400/403). Rogério Augusto, Marcos e Jheimeson foram citados (fls. 473, 475e 477).

Em instrução processual criminal foram ouvidas testemunhas (fls. 589/599). Houve desistência da oitiva de testemunha, o que foi homologado pelo Juízo (fls. 604), prosseguindo-se com os interrogatórios dos acusados (fls. 600/603).

Encerrada a instrutória, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 604/605).

Em sede de memoriais escritos, o Dr. Promotor de Justiça pleiteou pela parcial procedência da ação-penal, com a condenação de Rogério Augusto, Marcos e Jheimeson por infração ao artigo 33, § 4º, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, absolvendo-os da imputação do artigo 35, da Lei 11.343/06 (fls. 609/620).

A Defesa de Rogério Augusto pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso II ou VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pela aplicação do § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 e a restituição do automotor FIAT Siena Attractiv 1.4 (fls. 625/637).

A Defesa de Jheimeson requereu a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a aplicação do § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 (fls. 659/674).

A Defesa de Marcos, por sua vez, postulou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pela aplicação do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 para o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls.

677/684).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Quanto ao delito do artigo 35, da Lei 11.343/06, o conjunto probatório amealhado na fase judicial se mostra frágil. Isto porque não demonstrado o vínculo de estabilidade, entre Rogério Augusto, Marcos e Jheimeson, sendo que, conforme dominante jurisprudência, não basta, para caracterização do delito a mera união ocasional ou episódica.

"Enfim, pode-se até duvidar de uma conduta inocente por parte dos réus apelantes. É possível mesmo que reste em cada um dos agentes da lei - policiais, representantes do Ministério Público e magistrados - a íntima convicção relativa à culpabilidade dos acusados na condição de traficantes. No entanto, para uma condenação tão grave e de efeitos tão severos, o convencimento subjetivo há que restar, além das provas indiretas, minimamente provado" (TJMG - nos Autos nº 288397- 3 - j. 17/09/2002 - p. 20/09/2002).

Cabe ressaltar que, como cediço, na fase da denúncia vigora o princípio in dubio pro societatis da análise das provas e o inquérito-policial é peça meramente informativa destinada tão-somente a autorizar o exercício da ação-penal. Todavia, na sentença, se das provas emergem dúvidas da autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo. Neste sentido:

"Inquérito Policial - Valor deste que não pode ser tamanho que autorize a condenação apenas com seus elementos - Prova suficiente para o oferecimento da denúncia, mas não para a condenação - Absolvção mantida" (Relator: Renato Nalini - Apelação Criminal 94.764-3 - Mauá - 25.03.91).

"Inquérito policial - Natureza - Disciplina da Prova - O inquérito policial constitui mero procedimento administrativo, e de caráter investigatório, destinado a subsidiar a atuação do Ministério Público. Trata-se de peça informativa cujos elementos instrutórios - precípuamente destinados ao órgão da acusação pública - habilita-lo-ão a instaurar a persecutio criminis in judicio. A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela Polícia Judiciária na fase preliminar da persecução penal (informatio delicti) e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito. A investigação policial - que tem no inquérito o instrumento de sua concretização - não se processa, em função de sua própria natureza, sob o crivo do contraditório, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade e da instrução criminal contraditória. A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina como pela jurisprudência dos Tribunais (RT 522/396), cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo. Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia" (STF - 1ª Turma - REcr. nº 136.239-1/SP - RELATOR:- Min. Celso de Mello - DJU 14/08/92, pág. 12227).

Com relação ao artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, a materialidade delitiva consubstancia-se em auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 14/19), auto de exibição e apreensão (fls. 20/23) e laudo pericial de constatação (fls. 56/61), bem como pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 589/599) e, especialmente, pela confissão judicial de autoria (fls. 600/603).

Perante a D. Autoridade Policial, Marcos afirmou conhecer Jheimeson e Rogério Augusto. Um desconhecido do Paraná, cujo nome não sabe e nem como o encontrar, os agenciaram para trazer a droga até São Paulo, dando as coordenadas para levar até Osasco-SP. Juntamente com Jheimeson tinha a função de batedor, ou seja, alertar Rogério Augusto caso tivesse algum bloqueio policial. Para isso se utilizava do

veículo Hyundai HB20, enquanto Jheimeson usava o automotor FIAT Argo e Rogério o automóvel FIAT Siena. Quando chegaram em Osasco-SP, Jheimeson permaneceu em um posto de gasolina, enquanto foram ao local onde seria feita a entrega. Chegando lá, após alguns minutos, foram surpreendidos por policiais civis que localizaram as drogas que Rogério Augusto trazia em seu carro. Pelo serviço os três ganhariam R\$ 35.000,00 que seria dividido (fls. 8/9).

Jheimeson afirmou ser amigo de Rogério Augusto e também é motorista de aplicativo. Até o dia anterior nunca tinha visto Marcos, que é amigo de Rogério Augusto, que os apresentou. No dia anterior, Rogério Augusto lhe chamou para fazer o transporte de drogas de Cascavel-PR até Osasco-SP e, para tanto, receberia R\$ 3.000,00. De imediato aceitou e ambos marcaram de se encontrar às 18h. No local do encontro, além de Rogério Augusto estava também Marcos. Ambos disseram que sua função seria ir à frente e, caso tivesse polícia na estrada, avisar. Saíram do Paraná, indo na frente com o veículo Argo, RNW3E83, e atrás vinha Rogério Augusto, com as drogas no veículo Siena, IWK3A49, e Marcos no automotor HB20, QIV5E33, este também fazendo a escolta. Quando chegaram em Osasco-SP, parou em posto de gasolina, enquanto Rogério Augusto e Marcos foram entregar as drogas. Enquanto aguardava, foi abordado por policiais civis e recebeu voz de prisão (fls. 10/11).

Rogério Augusto asseverou conhecer Jheimeson do grupo de aplicativo de transporte urbano, e Marcos no seu dia a dia na empresa Engematsu, onde, vez ou outra acontecem eventos. Em um desses encontros, um desconhecido veio a lhes contatar, querendo a resposta de imediato para serviço. Dias depois recebia o contado para iniciar o trabalho, com as orientações para levar até Osasco-SP. Marcos e Jheimeson tinham a função de batedor, isto é, de lhe alertar caso tivesse algum bloqueio policial. Para isso Rogério Augusto estava utilizando o Hyundai HB20, enquanto Jheimeson utilizava o FIAT Argo. O interrogando estava no veículo FIAT Siena.

Quando chegaram em Osasco-SP, Jheimeson permaneceu em um posto de gasolina, enquanto foram ao local onde seria feita a entrega. Lá chegando, após alguns minutos, foram surpreendidos por policiais civis, que localizaram o entorpecente que trazia em seu carro, desconhecendo a quantia. Pelo serviço os três ganhariam R\$ 35.000,00 que seria dividido entre os três. Ato contínuo os policiais civis localizaram Jheimeson no posto de gasolina, prendendo-o (fls. 12/13).

A confissão extrajudicial da autoria, como é cediço, vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela contém (RT 95/563). É mister emprestar-lhe a necessária credibilidade, vez que vem corroborada pelas demais provas amealhadas aos autos. Neste sentido:

“Em regra, a prova constante do inquérito policial não deve ser desprezada, mormente em caso em que o delito ocorre sob a clandestinidade, como o furto. As confissões nele obtidas regularmente estando seus termos em consonância com as demais circunstâncias dos autos, têm valor probante e podem ser aceitas, se não elididas na fase judicial” (TACRIM/SP - Acrim 22.508).

Em Juízo, Rogério Augusto confessou a prática delitativa. Não precisava passar pelo que estava passando. Está arrependido e tem vergonha de ter feito o que fez. Acabou aceitando fazer o transporte em razão das dificuldades financeiras que tinha, inclusive estava desesperado porque o plano de saúde da sua filha estava atrasado. Trabalha como Uber e conheceu muita gente e conversava com os clientes. Conheceu um cliente e falou para ele de suas dificuldades financeiras. Ele fez a proposta para que o interrogando levasse a mercadoria de Cascavel para Osasco e pagaria doze mil reais. Soube que era droga no ato da viagem. Participaram do transporte Rogério e Marcos e inclusive receberia o pagamento ao término da viagem e o pagamento seria feito por Marcos. Marcos e Jheimeson ficaram na função de batedores. Não reagiu à abordagem policial, foi colaborativo e confessou espontaneamente os fatos. O veículo usado no transporte das drogas, um veículo Siena, pertencia a sua sogra Rosângela que não sabia que iria utilizá-lo para transporte de drogas. Já trabalhava com esse veículo há alguns meses como motorista de aplicativo. Trabalhava com aplicativo e também fora do aplicativo como motorista. Trabalhava com isso há dois anos.

A droga estava apenas no carro do interrogando.

O cliente que fez a proposta para que levasse a droga é Marcos Pereira da Silva.

Recebeu a orientação para deixar seu carro em certo ponto e depois foi buscar quando o carro já estava carregado. Como não tem experiência acabou chamando Jheimeson que era seu parceiro de aplicativo. Sabia que Jheimeson estava passando também por dificuldades, tinha que pagar a pensão e estava com o carro batido, pediu para que Jheimeson fosse na frente até porque não conhecia o Estado de São Paulo e nunca tinha vindo para cá. Ficou combinado que Marcos pagaria Jheimeson, no final da entrega, três mil reais. Marcos iria receber ao todo trinta e cinco mil reais dos quais pagaria ao interrogando e Jheimeson, além de despesas de combustível e pedágio. Nunca tinha feito serviços anteriores para Marcos envolvendo drogas e somente combinou com ele essa entrega na qual foi preso. Não tinha conhecimento que Marcos tinha envolvimento com drogas e que se soubesse não deixaria entrar em seu carro (fls. 600/601).

Jheimeson, igualmente, confessou a prática delitativa. Declarou que trabalhava como Uber e conhecia Rogério do trabalho. Rogério chamou e resolveu se aventurar para trazer a droga porque estava sem dinheiro e seu carro estava batido. Estava trabalhando com carro alugado e tem dois filhos. Aceitou transportar a droga e ia receber três mil reais. Não sabe dizer quem iria pagar. Veio como batedor e o carro de Rogério trazia as drogas. Não conhece Marcos e pelo o que tem conhecimento apenas seu carro veio como batedor. Nunca tinha feito isso antes e nunca tinha se envolvido com isso antes. Não combinaram outra entrega. Veio de Cascavel para a cidade de Osasco. Foi abordado em um posto de combustível. Estava aguardando Rogério retornar. Ele tinha ido fazer a entrega da droga. Não acompanhou Rogério até o local onde ele entregaria a droga, pois seu serviço era trazê-lo até Osasco. Não se recorda se conversou com Rogério enquanto estavam no trajeto. Não viu um HB20 acompanhando durante o trajeto. Estava dirigindo um veículo FIAT Argo. O veículo era locado na cidade de Cascavel para trabalhar como Uber. Tinha alugado esse veículo há um mês, mas já trabalhou com outros veículos anteriormente. Não sabe dizer de quem era o veículo Siena dirigido por Rogério. Confessou a sua função de batedor assim que foi abordado pelos policiais. Declara seu arrependimento e nunca mais pretende se envolver criminalmente (fls. 602).

Marcos negou a associação para fins de tráfico. É trabalhador. Declarou que estava passando por um momento difícil em sua vida. Estava há seis meses separado após um casamento de vinte e um anos, sendo que tem dois filhos e estava com dificuldades para pagar a pensão. Estava lutando, trabalhando há sete anos para uma empresa e fazendo trabalhos de entrega. Comentou com algumas pessoas que estava passando por dificuldade financeira e acabou sendo envolvido por uma pessoa que lhe fez uma proposta para solução desse problema. Acabou aceitando a proposta para trazer uma mercadoria de Cascavel para São Paulo. Receberia trinta e cinco mil reais. A princípio achava que era eletrônico. No dia combinado essa pessoa pegou o carro de Rogério e carregou. Quando ele entregou, ficaram sabendo que era droga, mas estavam precisando do dinheiro e aceitaram trazer a droga para São Paulo. Foi como batedor no carro de Rogério e então nesse dia soube que Rogério tinha chamado um companheiro de serviço como batedor também. Rogério iria passar parte do valor dele para essa pessoa. Combinou com Rogério que receberia trinta e cinco mil reais, dividiriam as despesas da viagem e praticamente dividiriam o valor meio a meio. Pelo que Rogério lhe disse, daria três mil reais para Jheimeson. Não conversou com os demais acusados de outras viagens envolvendo drogas. Aliás, essa foi a sua única e última vez (fls. 603).

Infere-se que a confissão representa idôneo liame entre a autoria e o evento perpetrado, encontrando-se corroborada pelas demais provas produzidas, inclusive pelas confissões extrajudiciais de autoria. Deve, pois, ser considerada sincera. Neste sentido:

"Confissão Judicial - Ausência de circunstância que evidenciem insinceridade - Suficiência - Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa". (Ap. 470.903-2-SP - 8a C. - TACrim - j. 08.10.87 - Rel. Juiz Canguçu de Almeida).

Outrossim, não comprovado os alegados estados de necessidade, inviável é a

aplicação do artigo 24, do Código Penal. Ademais, outro caminho lícito era possível seguir, mas optaram pelo crime.

A testemunha Policial Civil Onassis asseverou que foi recepcionada na Delegacia denúncia, informando que no endereço da ocorrência haveria entrega de grande quantidade de entorpecente vinda de outro Estado no final de semana. Solicitaram trabalho de campo ao Delegado e na data fizeram campana. Avistaram dois veículos chegarem ao local dando a impressão que um estava escoltando o outro. Um dos motoristas desceu do veículo. Era um Siena que estava com as drogas e um dos abordados. Não se recorda do modelo do outro veículo que estava com outro abordado. Neste outro veículo nada foi apreendido. Foi feita a entrevista com ambos e depois, em solo policial, eles informaram que havia um terceiro indivíduo que também estava junto e aguardava no posto ali próximo. Foram até o local e abordaram esse terceiro indivíduo. Todos eram do Paraná e explicaram a situação, sendo que dois eram batedores e o outro levava a droga.

Não houve resistência e a ocorrência, pelo contrário do que pensaram quando viram dois carros e poderia ter troca de tiros, foi tranquila. Eles falaram os fatos espontaneamente (fls. 589).

A testemunha Policial Civil Allan declinou que houve denúncia anônima feita na Delegacia que em local declinado haveria entrega de entorpecente. Solicitaram à Autoridade Policial para fazerem a diligência de campo. Em campana avistaram dois veículos como se um estivesse escoltando o outro. Um veículo cinza e outro preto. Um dos abordados saiu do carro e demonstrou nervosismo. Eles foram abordados e um deles confessou de imediato que estava transportando a droga e o outro era escolta. Foram levados à Delegacia onde houve a informação que um terceiro indivíduo estava esperando no posto de gasolina. Foram até o local e fizeram a abordagem dele. Não houve resistência à prisão. Eles confessaram a prática dos fatos no local onde as drogas foram apreendidas.

Houve apreensão de tabletes de maconha em grande quantidade. Não se recorda o número correto. A droga estava no porta-malas e também embaixo da tapeçaria no carro Siena. Não tem condições de apontar quem estava no veículo Siena (fls. 590).

A testemunha da Defesa, Johnathan Israel, relatou que não presenciou a prisão dos acusados. Conhece Jheimeson desde 2014, pois trabalharam registrados no mesmo local, que era uma casa de material elétrico. Depois o declarante saiu e foi trabalhar como motorista de aplicativo e acabou indicando esse serviço para Jheimeson. Jheimeson começou a trabalhar com aplicativos para ter renda extra. Depois pediu demissão para trabalhar apenas com aplicativos. Teve um período que Jheimeson passou por grande dificuldade financeira, com um casal de filhos e acabou batendo o carro enquanto estava trabalhando de Uber. Nunca ouviu comentários de envolvimento de Jheimeson com o tráfico e se surpreendeu.

O acidente a que se referiu ocorreu em meados de 2021. Depois da colisão Jheimeson alugou um veículo para poder trabalhar. De Rogério só sabe dizer que trabalha de aplicativo de Uber, mas não tem detalhes de suas condições. Não conhece Marcos (fls. 591).

A testemunha da Defesa, Edson, declinou que não presenciou a prisão dos acusados. Conhece Marcos desde 2000 e pode informar que ele é trabalhador e honesto. Marcos trabalhou na Companhia de Saneamento de Cascavel e depois em outro local que não se recorda o nome e depois em empresa de assessoria de peças pesadas. Desde que conhece Marcos desconhece qualquer fato que o desabone. Marcos tem dois filhos, pelo o que se recorda menores de idade (fls. 592).

A testemunha da Defesa, Manoel Antônio, afirmou que não viu a prisão dos acusados. Conhece Marcos que era prestador de serviço da empresa. Ele tem boa índole, desconhece qualquer fato que o desabone, fazia serviços que envolviam confiança e tem família. O declarante possui empresa com trinta e sete anos de funcionamento e trabalha com peças de trator e reformas em Cascavel. Conhece Marcos há mais ou menos sete anos desde quando ele prestava serviço de motoboy para vários clientes e depois passou a trabalhar apenas para o declarante. Marcos pediu uma licença porque não estava conseguindo trabalhar, pois tinha dívidas com amigos e queria vir para São Paulo pedir dinheiro para parentes com a intenção de saldar dívidas. Liberou Marcos para que resolvesse seus problemas pelo tempo que fosse necessário. Ficou

surpreso quando Marcos foi preso por tráfico de drogas. Tinha a confiança nele até para mandar ele até a sua casa. Não conhece Rogério (fls. 593).

A testemunha da Defesa, Ronaldo, asseverou não viu a prisão dos acusados. Conhece Marcos que já trabalhou consigo. Ele é excelente pessoa e inclusive trabalhava fora do horário. Ficou chocado com a prisão.

Não conhece Rogério (fls. 594).

A testemunha da Defesa, Idima Idulia, declinou que não presenciou a prisão dos acusados. Conhece Rogério há aproximadamente sete anos. É seu vizinho e mora no fundo de sua casa. É casado e tem uma filha. Trabalha como Uber. Inclusive pagava serviços para Rogério como lhe levar ao serviço (fls. 595).

A testemunha da defesa, Felipe Wellington, cunhado de Rogério, narrou que não viu a prisão. Rogério é casado com sua irmã há sete anos. É trabalhador e frequenta a igreja. Ele estava trabalhando como Uber e inclusive passou convite ao declarante que trabalhou por um período. Ele tem uma filha pequena. Recebeu a notícia com choque, pois via em Rogério pessoa de boa índole e nunca imaginou isso.

Antes dos fatos, Rogério chegou a comentar que estava passando dificuldades financeiras. Tudo vem aumentando e o trabalho de Uber não é fácil. O veículo Siena apreendido com Rogério é de sua mãe. Sua mãe emprestou o veículo para que trabalhasse de Uber e inclusive o declarante já emprestou anteriormente (fls. 596).

A testemunha da Defesa, Andresa Carolina, cunhada de Rogério, afirmou que não viu a prisão. Conhece Rogério há sete anos e ele é pessoa trabalhadora e inclusive foi gerente de vendas dele. Rogério é honesto, trabalhador, bom marido, bom pai e tem uma filha pequena. Nunca imaginou isto dele. Ele estava trabalhando como Uber em Cascavel e inclusive a declarante confiava os filhos para Rogério levar à escola. Uma semana antes da viagem Rogério chegou a comentar que estava com dificuldades financeiras declarando que estava desesperado porque o combustível está com valor alto, Laura não estava bem de saúde e o boleto do plano de saúde estava atrasado. Perguntou à declarante se conhecia algum trabalho em vendas e inclusive tinha feito um currículo. O veículo que estava com Rogério é da mãe da declarante, Rosângela (fls. 597).

A testemunha da Defesa, Rosângela de Fátima, asseverou que Rogério é casado com Maria Alice, sua filha. Quando soube que Rogério foi preso tomou um grande susto. Ele sempre foi família, participava da igreja, bom pai e tem uma filha pequena. Rogério estava com dificuldades financeiras e chegou a comentar que a gasolina tinha aumentado e as coisas estavam difíceis. Inclusive ajudava entregando cartão para ele comprar as coisas. Quando ele ia pagar o valor emprestado ele dizia se poderia esperar mais um pouco, pois estava juntando e iria trabalhar aos finais de semana e de noite como Uber. Inclusive ele usava o veículo da declarante para trabalho. O veículo Siena apreendido com Rogério é da declarante (fls. 598).

A testemunha da Defesa, Sônia, tia de Rogério, afirmou que ele é casado com a sobrinha da declarante. Conhece ele há sete anos e ele tem uma filha. Ele participava na paróquia, inclusive tocando. Ele é boa pessoa e correto.

Rogério estava trabalhando como Uber. Indicava o trabalho de Rogério. Não conhece Marcos e nem Jheimeson (fls. 599).

Ressalte-se que nenhum das testemunhas da Defesa presenciou a abordagem e o momento da prisão, limitando-se a abonar conduta pretérita e atestar bons antecedentes dos acusados.

Tem-se, portanto, que os testemunhos policiais demonstram a veracidade dos fatos, até porque responderam as indagações formuladas, apresentando as mesmas circunstâncias, tanto na fase extrajudicial quanto judicialmente, no aspecto principal. Inclusive, estando corroborados pelas confissões extra- e judiciais dos acusados.

É cediço que o testemunho policial não é afetado, positiva ou negativamente, pela função que exerce. A condição funcional não confere ao seu testemunho maior força persuasória e nem o inquina de suspeição. O valor probante de sua versão é aferido pelo mérito e de acordo com o grau de confiabilidade segundo a harmonia das provas coligidas aos autos. Neste sentido, vasta é a jurisprudência proclamada pela suficiência, se coesos os testemunhos policiais, para embasar o édito condenatório. "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por

policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial" (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94)

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Droga apreendida nas mãos dos apelantes - Grande quantidade - Policiais que se infiltraram na quadrilha afim de se passarem por traficantes - Prova colhida que aliada ao depoimento dos policiais que autorizam a condenação - Recurso não provido. É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V.U.)

As provas são uníssonas e coesas quanto à responsabilidade criminal de Rogério Augusto, Jheimeson e Marcos. Houve denúncia anônima na Delegacia, de que haveria entrega de grande quantidade de entorpecente vinda de outro Estado no final de semana. Em diligências os policiais civis avistaram dois veículos chegarem ao local. Um dos motoristas desembarcou de um Siena que estava com as droga. No outro veículo nada foi apreendido. Indagados, ambos informaram que havia uma terceira pessoa, em um posto ali próximo, onde foi abordado. Todos eram do Paraná, sendo que dois vieram como batedores e o outro trazendo a droga. Tanto extrajudicialmente, quanto em Juízo, Rogério Augusto, Jheimeson e Marcos confirmaram a prática delitiva.

Para caracterização do delito de tráfico ilícito de entorpecentes dever-se-á atender à natureza e a quantidade da substância entorpecente, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Seguindo essas variantes houve plena demonstração do animus de traficar, sendo robusto o material cognitivo.

Ora, os elementos citados são suficientes e indicam que o material tóxico apreendido se destinava ao comércio ilícito.

Os acusados foram denunciados por transportarem e trazerem com eles entorpecente cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários, tais como a confissão extrajudicial, a quantidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes dos agentes, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciem a atividade delituosa" (TJRJ - ApCrim 5.492 in Direito Concreto, v. 5, p. 191).

"Desimporta se o agente não chegou a vender o tóxico, pois trazer consigo, já é delito consumado, segundo uma das normas múltiplas que contém o art. 12 da lei respectiva" (TJRS - AC 68.305.178-3 - Rel. Milton dos Santos Martins - RJTJRS 107/59).

Com esta prova a respeito da finalidade de entrega do entorpecente a consumo de terceiros não há que se cogitar da desclassificação para o delito preconizado no artigo 28, da Lei 11.343/06. Anote-se que a eventual condição de usuário não exclui a traficância. Ainda, a quantidade de entorpecente apreendida, 94,1kg de maconha não é condizente com a condição de mero usuário.

Ainda, configurado o tráfico de entorpecentes entre Estados da Federação, observando-se que Marcos, Rogério Augusto e Jheimeson confessaram ter recebido o entorpecente no Estado do Paraná, trazendo-o para o Estado de São Paulo, sendo abordados em Osasco-SP. Incide, portanto, o artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06. Conclui-se, pois, pela parcial procedência da presente ação penal com a consequente condenação de Rogério Augusto Ratti, Marcos Pereira da Silva e Jheimeson Balzan por

infração ao artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06. Passo à dosimetria da pena.

Agiram com intensidade dolosa incomum para os delitos da espécie a justificar a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal, a teor do autorizado pelo artigo 59, do Código Penal. Veja-se que foram apreendidos aproximadamente 94 kg de maconha, ou seja, quantia bastante elevada. Portanto, a pena, relativa ao delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, será aumentada na razão de 1/3.

Fazem jus à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, como é cediço, ao Magistrado não é dado transgredir os limites que a lei fixa para as penas, salvo nos casos em que tal faculdade é expressamente outorgada. Assim, inadmissível é a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda quando se cuide de agente confesso extra- e judicialmente:

"Na aplicação da pena, as circunstâncias atenuantes, de consideração obrigatória, não permitem a fixação da reprimenda em parâmetros inferiores ao mínimo legal, não havendo confundi-las com as causas de diminuição de pena, que, estas sim, ensejam essa possibilidade". (RJD 23/299)

É de se observar que a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça não revogou sua Súmula 231. A atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal continua não tendo o condão de reduzir a reprimenda para abaixo do mínimo legal.

Neste sentido, inclusive, já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal". III - In casu, a forma da confissão da paciente, para se beneficiar de tese da defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelo juiz de origem que a paciente admitiu a imputação dos fatos relativos ao dia 06/01/2016. IV - Destarte, considerando a utilização da confissão para formara convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.682/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 431.336-RS. Relator: Ministro Félix Fischer. Julgamento: 12 de junho, 2018. Publicação: 15 de julho, 2018).

São primários e não ostentam maus-antecedentes criminais.

Verificada a ininteressadualidade da traficância, observando que Marcos, Rogério Augusto e Jheimeson confessaram a prática delitiva, detalhadamente, bem como as circunstâncias do delito, o artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06 será aplicado na proporção de 1/6.

É pertinente a redução prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.887.511-SP, que fixou diretrizes acerca da consideração da quantidade e variedade de entorpecentes na dosimetria da pena.

"PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU

MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença” (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Assim, tratando-se de agentes primários, a redução deve se dar em seu grau máximo, ou seja, 2/3, conforme o preconizado pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Considerando os parâmetros acima e os demais critérios preconizados pelo artigo 59, do Código Penal, fixo, para Rogério Augusto, Marcos e Jheimeson, considerando a identidade objetiva e subjetiva entre eles, a pena-base acima do mínimo legal, conforme o já expendido, na proporção de 1/3, ou seja, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, calculados pelo valor mínimo. Pela incidência do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, reconduzo a reprimenda a seu patamar mínimo, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, não podendo ficar aquém disso, conforme o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 231. Não outras há atenuantes ou agravantes. Pela incidência do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, aumento a reprimenda em 1/6, perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Diminuo a pena em 2/3 com esteio no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, totalizando 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de

194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados na base. Não há outras causas de diminuição ou de aumento. À míngua de outras causas legais de alteração torno estas penas definitivas.

Em face do disposto no artigo 33, alínea c, do Código Penal e artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixo o regime inicial aberto.

Por força da Resolução 5/2012 do Senado Federal, não havendo óbice, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo nacional à A.A.C.D./Osasco-SP e prestação de serviços à comunidade, por igual prazo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO ROGÉRIO AUGUSTO RATTI, JHEIMESON BALZAN e MARCOS PEREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, a cumprirem, em regime inicial aberto, a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo nacional à A.A.C.D./Osasco-SP e prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, por incursos nas penas do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, ABSOLVENDO-OS, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

Diante do quantum da reprimenda aplicada e da substituição levada a efeito, poderão Rogério Augusto, Jheimeson e Marcos recorrerem em liberdade. EXPEÇA-SE de imediato o competente ALVARÁ de SOLTURA clausulado.

No mais, autorizo a destruição do entorpecente nos termos regimentais.

Quanto ao automotor FIAT Siena Attractiv 1.4, considerando a documentação juntada a fls. 638, bem como que teria sido emprestado a Marcos por terceiro que desconhecia a finalidade ilícita, DEFIRO sua LIBERAÇÃO. Oficie-se à Autoridade Policial, autorizando as providências necessárias no sentido de LIBERAR o VEÍCULO FIAT Siena Attractiv 1.4, 9BD19713MF3248875, apreendido nos presentes autos, a ROSÂNGELA DE FÁTIMA BITTENCOURT, qualificada nos autos, independente do pagamento de taxas, multas ou despesas com remoção e estadia, salvo se houver apreensão decorrente de infração ou medida administrativa estabelecida na Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Osasco, 23 de março de 2022.